

1501388-18.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... e unidade de desígnios, para fins de tráfico, traziam consigo e armazenavam drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na denúncia, durante patrulhamento de rotina, policiais visualizaram Otacílio em frente a um imóvel conhecido por recorrentes delações de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação policial, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501388-18.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501388-18.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otacílio dos Santos de Paula e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Otacílio dos Santos de Paula e Marcus Vinícius Ribeiro Pereira foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque por volta das 19h58min de 6 de outubro de 2021, na Rua Vitor Joaquim Vieira, nº 75, Vila Prosperidade, Taubaté, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, para fins de tráfico, traziam consigo e armazenavam drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na denúncia, durante patrulhamento de rotina, policiais visualizaram Otacílio em frente a um imóvel conhecido por recorrentes delações de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação policial, o réu empreendeu fuga, motivando a perseguição, e correu para o interior do imóvel.

No interior de um quarto, os policiais encontraram e abordaram o corréu Marcus, com quem localizaram 3 porções de cocaína e um aparelho celular. Em seguida, Otacílio foi flagrado no telhado da residência.

Em vistoria pelo local, no quarto ocupado por Marcus, foi localizado um caderno com contabilidade do tráfico em uma gaveta da cômoda, bem como uma sacola contendo R\$ 569,00, 52 invólucros de crack, 116 eppendorfs de cocaína e 2 invólucros de maconha, escondida no vão de uma telha que encobre o cômodo.

Indagados, os réus negaram o tráfico de drogas e afirmaram que o imóvel pertencia a Otacílio.

A denúncia foi recebida às fls. 112/118.

Citados pessoalmente (fls. 128 e 129), os réus apresentaram resposta escrita à acusação às fls. 144.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Combateu a negativa de autoria dos réus. Enfatizou a prova testemunhal e os elementos que levaram os policiais a efetuarem a diligência. Defendeu a imposição de pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas. Aduziu que Otacílio ostenta Maus antecedentes e é reincidente. Rechaçou a possibilidade de aplicação do redutor previsto na lei de drogas. Pediu fixação de regime inicial fechado e a decretação de perda do bem imóvel.

A Defesa suscitou a nulidade da diligência policial por indevida violação de domicílio. Requereu a absolvição de Otacílio pelo tráfico e a desclassificação da conduta imputada a Marcus para o artigo 28, da Lei 11.343/06. Argumentou que não foi demonstrado o concurso de agentes. Subsidiariamente, pediu a imposição de pena-base mínima a Marcus, que possuía menos de 21 anos na data dos fatos. Rogou pela redução da pena na terceira fase, com fulcro no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Defendeu a fixação de regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. Em relação a Otacílio, argumentou que a reincidência permite módico aumento da pena na segunda fase.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu aos réus a autoria de tráfico de drogas, dando-os como como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade das provas por violação de domicílio. Afirma que os policiais invadiram a residência do réu, local onde foram encontradas as drogas apreendidas, sem motivo justificável ou mandado judicial para tal fim. Dessa forma, entende que a prova não pode ser utilizada em desfavor do réu por ser ilícita.

A arguição preliminar, com a devida vênia, não procede.

Do conjunto probatório se verifica que, no caso, a diligência policial não atentou contra inviolabilidade domiciliar, pois os policiais estavam em patrulha rotineira quando o comportamento do corréu Otacílio chamou a atenção. Disseram que a região e o próprio imóvel em que foram detidos os acusados são conhecidos pelo tráfico de drogas. Informaram que Otacílio correu em fuga da polícia assim que percebeu a aproximação da viatura, escalando o telhado de sua residência para tentar se furtar da abordagem. Enfatizaram que perseguiram o acusado até a residência palco dos fatos, onde o corréu Marcus também foi abordado. Aduziram que, além das diversas porções de drogas localizadas no imóvel, tanto na posse de Marcus como escondidas

na casa, foram encontradas anotações relativas ao comércio de drogas e diversas cédulas de dinheiro.

Assim, conclui-se que os policiais tinham fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas consistentes, inicialmente na fuga do corréu e na prévia inteligência policial sobre a traficância exercida no imóvel, posteriormente somadas à entrevista pessoal com ambos, apreensão de anotações com contabilidade do tráfico e de diversas porções de drogas que os réus estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, a prova constante dos autos é suficiente a demonstrar que havia elementos seguros, objetivos e racionais a justificar a entrada no domicílio sem o respectivo mandado. Presente estava, ali, a justa causa, consubstanciada no estado de flagrância dos réus vislumbrado pelos agentes policiais.

Assim, a prova colhida não está maculada pela invasão de domicílio, diligência que se fez com a guarida da lei e com respaldo no entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Nesse sentido, também, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, como se vê:

“PRELIMINAR - nulidade da prova em face da invasão de domicílio - inocorrência - fundada suspeita consistente na visualização do réu em local apontado pela denúncia anônima e com as características indicadas pelo denunciante - fuga do réu após avistar a guarnição policial - guarda de entorpecente que configura estado flagrancial - afastada a preliminar. MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA - depoimento de policiais que indica a apreensão de droga na residência do réu - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela - versão do réu de que a residência diligenciada não era sua - versão que não restou demonstrada. TRÁFICO - destinação a terceiros - quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; e denúncia anônima - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. PENA - primeira fase - base fixada no mínimo - manutenção - segunda fase - agravante da reincidência - aumento em 1/6 - 3ª fase - ausentes causas de aumento e diminuição da pena - redutor não reconhecido em face da reincidência - manutenção - improvimento ao apelo REGIME - considerável quantidade de drogas - natureza de parte dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - alta reprovabilidade e periculosidade - reincidência específica - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime fechado - necessidade - detração - não cabimento no presente caso - regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis - substituição da pena reclusiva por restritivas de direito - impossibilidade - alta reprovabilidade - quantum de pena - reincidência específica - improvimento ao apelo” (Apelação Criminal 1501914-97.2019.8.26.0571; Relator (a): Mens de Mello; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga; Data do Julgamento: 25/01/2022)

A materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), termo de depoimento (fls. 3/6), termo de interrogatório (fls. 7 e 24), auto de qualificação (fls. 8 e 25), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 40/41), laudo pericial (fls. 145/148) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Lucas Faria Costa, ouvida em juízo, disse que estava em patrulhamento pela via e tinha ciência do movimento de tráfico no local. Afirmou que Otacílio fugiu ao perceber a aproximação da polícia, o que motivou a abordagem. Disse que perseguiu o acusado no imóvel e abordou o corréu. Pontuou que encontrou diversas sacolas com drogas escondidas nas telhas da casa. Informou que Otacílio correu e subiu no telhado da casa, ao passo que Marcus permaneceu no interior do imóvel. Relatou que não havia outras pessoas na residência, que ocupava a parte dos fundos de um terreno. Disse que foi apreendido um caderno com contabilidade do tráfico, no qual constavam apelidos anotados. Informou que Otacílio morava no imóvel. Já abordou os acusados em outra ocasião. Disse que o local era conhecido pelo tráfico, mas estava em patrulhamento de rotina. Segundo informado no momento dos fatos, Marcus estava consumindo drogas no local, pois havia brigado com familiares. Informou que Otacílio estava no meio da via pública quando percebeu a aproximação da viatura policial. Sabia que Marcus morava na região dos fatos. Aduziu que Marcus tinha poucas porções de cocaína perto de si. Disse que havia diversas sacolas no telhado da casa. Afirmou que efetuou a abordagem em torno das 19h20min e não foi acompanhado por moradores do outro imóvel situado no terreno.

Everton Souza Santos disse que Otacílio empreendeu fuga ao perceber a aproximação da polícia, o que motivou a abordagem. Relatou que encontrou o corréu Marcus no interior do imóvel e Otacílio subiu no telhado para tentar fugir. Disse que Marcus trazia consigo três pinos de cocaína. Otacílio não tinha nada de ilícito consigo, mas havia diversas porções de drogas no telhado do imóvel. Aduziu que Otacílio disse que morava no local, mas negou ciência sobre as drogas apreendidas no local. Afirmou que Marcus disse que frequentava o local para consumir drogas. Disse que o local era conhecido ponto de tráfico e objeto de reclamações de vizinhos. Aduziu que os acusados moravam na região. Contou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro. Informou que Otacílio estava na calçada, mas não em frente a sua casa. Afirmou que a casa ficava nos fundos de um terreno. Segundo informado pela irmã do réu, a residência estava em estado de abandono e o corréu utilizava o imóvel para consumo de drogas.

Interrogado, o réu Otacílio dos Santos de Paula negou a autoria dos fatos, pois sequer sabia da existência de drogas. Asseverou que estava morando na casa de sua irmã. Foi informado por uma vizinha que havia alguém pulando o muro da casa durante a madrugada. Disse que apenas ia ao local para fumar maconha e limpar a casa. Afirmou que correu para o interior da casa assim que viu a viatura policial. Não soube dizer a razão pela qual correu para o telhado da casa. Não estava carregando drogas, mas é usuário de maconha, crack e cocaína. Não soube explicar a origem das drogas encontradas no telhado. Conhecia o corréu Marcus do bairro. Segundo informado pelos policiais, havia cocaína, crack e dinheiro no telhado. Não viu as drogas no interior do imóvel. Disse que a casa estava trancada e ninguém morava no local, pois sequer havia fornecimento de água e energia elétrica. Contou que a porta de madeira estava trancada com uma corrente.

Marcus Vinícius Ribeiro Pereira, interrogado em juízo, asseverou que estava no local apenas para consumir drogas. Disse que havia brigado com sua família e entrou no imóvel para consumir drogas. Afirmou que não sabia que havia drogas no local. Aduziu que apenas viu o réu correndo pela casa e, em seguida, policiais militares. Disse que não correu, pois não sabia que havia drogas no local. Confessou que tinha três pinos de cocaína para seu uso pessoal. Contou que mostrou as drogas que tinha consigo aos policiais. Aduziu que Otacílio morava com sua esposa em outro local. Afirmou que, segundo informado pela polícia, algumas porções de cocaína foram apreendidas no telhado da casa. Acreditava que a casa estava abandonada. Afirmou que está arrependido. Disse que comprava drogas na própria rua dos fatos, mas não diretamente do réu. Asseverou que já havia conversado com o corréu Otacílio, razão por que pulava o muro do imóvel para consumir drogas.

Bem provadas a autoria e a materialidade, nos termos previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Observo que a conduta dos réus se enquadra em diversos verbos do núcleo do tipo, notadamente trazer consigo, ter em depósito e armazenar drogas, resultando, assim, configurada a tipificação do crime em questão.

Cumpru destacar que, em razão de patrulhamento de rotina realizado na região da residência palco do delito, os réus foram presos em flagrante na posse de grande quantidade de drogas que estava armazenada na casa do corréu Otacílio.

O estado de flagrância, só por si, caracteriza de forma indubitável a autoria e a própria materialidade, não havendo lógica capaz de fugir a essa interpretação.

Os réus, apanhados no interior da casa utilizada como verdadeiro centro de operações do tráfico de entorpecentes, como aqui foram, abastecidos de grande quantidade de cocaína, dinheiro e caderno com anotações do narcotráfico simplesmente não têm como justificar a situação.

Ao estado flagrancial, somam-se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados.

Ouvidos durante a fase administrativa, os policiais narraram de forma uníssona que estavam em patrulhamento de rotina no local e horário dos fatos. Asseveraram que desconfiaram da atitude de Otacílio, que tentou fugir pelo telhado de sua própria casa, mas foi perseguido e capturado. Aduziram que, durante a perseguição, no interior da residência, encontraram o corréu Marcus na posse de três porções de cocaína. Após buscas pelo imóvel, localizaram no vão de uma telha uma sacola contendo dinheiro e diversas drogas, dentre elas inúmeras porções de cocaína com embalagem idêntica àquela que estava na posse de Marcus. Ouvidos em juízo, os agentes públicos reiteraram a mesma narrativa.

Interrogados, os réus negaram qualquer vínculo com o tráfico de drogas. Marcus disse que entrou no local sem autorização de Otacílio apenas para consumir drogas. Aduziu que conhecia o corréu Otacílio, mas não havia comprado dele as drogas. Informou que adquiriu apenas as três porções de cocaína que carregava consigo na mesma rua em que estava. Otacílio, por sua vez, disse que estava morando em outro local e mantinha a residência trancada com cadeado. Disse que foi ao imóvel, pois o avisaram que havia alguém lá. Não soube explicar o motivo de ter fugido da polícia e subido no telhado.

No caso em exame, sobre os fatos, tem-se a palavra dos policiais em confronto com as alegações dos réus.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais não constitui razão bastante para infirmar o teor dos depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova em sentido contrário, considerando especialmente a segurança, firmeza, linearidade e verossimilhança dos depoimentos.

Registro, ainda, que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

Pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos, notadamente o encontro de grande quantidade de droga, dinheiro e anotações relativas ao comércio de entorpecentes.

Evidentemente mendaz a versão dos acusados, pois se mostraram absolutamente dissociadas dos demais elementos de prova dos autos.

Imprescindível ressaltar que as drogas localizadas com Marcus tinham a mesma embalagem daquelas escondidas no telhado da casa, local que Otacílio buscou como abrigo da polícia. Segundo informado por Otacílio, sua casa estava trancada com cadeado, mas mesmo assim Marcus conseguiu acessar seu interior tranquilamente, local em que foi flagrado por policiais na posse de cocaína.

Acrescente-se, por outro lado, por relevante, que a quantidade de porções individualmente embaladas dos entorpecentes e o modo em que foram encontrados dão conta da traficância exercida. Juntos, os acusados armazenavam 119 eppendorfs de cocaína, 52 porções de crack e 2 invólucros de maconha, além de R\$ 569,00 em cédulas trocadas de baixo valor e um caderno contendo anotações referentes ao narcotráfico (fls. 42/49).

Como assentado no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como elas estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes" (Apelação nº 3004054-64.2013.8.26.0272, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 20.7.2017).

Quem é apanhado, como aqui, manuseando, armazenando e mantendo em depósito grande quantidade de drogas, já embalada para entrega e consumo imediato, não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância.

Analisadas as teses da acusação e da respectiva defesa, conclui-se que os réus eram, na data dos fatos, imputáveis. Tinham plena consciência da ilicitude de seus atos, não vindo em socorro quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

A prova é certa, segura e da conta do cometimento da conduta imputada aos réus, que devem responder penalmente por seus atos.

Estabelecida a responsabilidade criminal dos réus, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nélson Hungria e obediente ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria, impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, do Código Penal, a natureza e

a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social dos agentes.

A quantidade total das drogas não pesa em desfavor dos réus.

A personalidade dos agentes – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que mentiram em Juízo ao alterar a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte dos réus, que se valem da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo “A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena”, da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação

Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie. Acerca da conduta social dos réus, não há elementos para que se proceda à sua valoração. Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante. O sujeito passivo dos crimes é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', de forma que o comportamento da vítima é irrelevante.

Otacílio dos Santos de Paula

O corréu ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, razão pela qual me valho de uma das condenações com trânsito em julgado para majorar a reprimenda nessa primeira fase da dosimetria (fls. 65/76; processos n. 7002106-61.2012.8.26.0625 e 0025007-45.2012.8.26.0625).

Assim, à reprimenda mínima cominada em abstrato acresço 1/3, fixando a pena-base no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Na segunda fase, impende reconhecer a reincidência do réu, conforme se extrai das certidões de fls. 65/76 (processo n. 0023339-10.2010.8.26.0625). Por outro lado, não concorre qualquer circunstância atenuante, razão pela qual aumento a pena em 1/6, que passa a totalizar 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo em definitivo a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Inadmissível a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu não cumpre os requisitos previstos, especialmente por ser reincidente (fls. 23/27).

De se anotar que a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante, o traficante fortuito. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o fechado, em razão da

quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e §3º, do Código Penal.

Ademais, trata-se de condenação por tráfico de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta, que pode ser verificada pela expressiva quantidade de porções individuais, também exige maior rigor por parte do Estado.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois o réu não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente pela quantidade de pena imposta e pela reincidência. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena, considerando que também não preenche os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso em exame o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantida a custódia cautelar nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Marcus Vinícius Ribeiro Pereira

O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 51/52).

Assim, partindo da pena mínima cominada em abstrato ao tráfico de drogas, acresço-a de 1/6 pela personalidade negativa e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas, razão pela qual as reprimendas se mantêm inalteradas.

Ausente qualquer causa de aumento a ser aferida na terceira fase da dosimetria, reconhece-se a causa de diminuição prevista no inciso § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Registro, pelo que se extraiu das provas colhidas, que o réu é tecnicamente primário e tem bons antecedentes (fls. 77/80). Não fez prova o Ministério Público de que o réu se dedique ao crime ou faça parte de associação criminosa, não sendo suficiente para tanto o reconhecimento de estar ele perpetrando o crime em companhia do réu Otacílio. Ao que consta dos autos, o réu apenas trazia consigo algumas poucas porções de droga, conduta isolada e que possibilita prover-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive. Destarte, faz jus à redução em patamar máximo (2/3), razão pela qual diminuo a reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa.

Tendo em conta a literal disposição do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, o regime adotado para o início do cumprimento de pena será o aberto.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Excepcionalmente, no caso concreto, se afigurapossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Isso porque a pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência, o réu confessou o crime e não é reincidente. Além disso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Considerando que a reprimenda é superior a um ano, nos termos do artigo 44, § 2º, da Lei Penal, de rigor a substituição por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que em razão da quantidade da pena imposta e das circunstâncias judiciais, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Além disso, foi fixado o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. Evidente que nas circunstâncias do caso concreto, quantidade da pena privativa de liberdade, substituição da pena e fixação do regime aberto, a custódia cautelar do réu se afigura incompatível.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento tão somente dos valores apreendidos com os réus em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado com eles (fls. 134).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de:

- a) condenar o réu Otacílio dos Santos de Paula à pena 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento de pena em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade;
- b) condenar o réu Marcus Vinícius Ribeiro Pereira à pena de de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do corréu Marcus Vinícius Ribeiro Pereira.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar os réus para procederem ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação dos réus;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA